

1500870-53.2021.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131307/2021 - DEL.POL.UBATUBA,

17908340 - DEL.POL.UBATUBA, 1339/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2131307 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500870-53.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500870-53.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131307/2021 - DEL.POL.UBATUBA,

17908340 - DEL.POL.UBATUBA, 1339/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2131307 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DA SILVA BARROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de IGOR DA SILVA BARROS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme se extrai da denúncia, na data e local dos fatos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 74 porções de cocaína (75g), 140 pedras de 'crack' (40g), 01 tablete de 'maconha' (235g) e 22 porções de 'maconha' (29g), sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu, o qual, ao perceber a presença da viatura, começou a arrumar algum objeto na cintura. Seguiu-se a abordagem e, em busca pessoal, foi localizada com Igor uma bolsa pequena, cor preta, contendo 140 pedras de 'crack', 22 porções de maconha, 01 tablete também de maconha (235g), 74 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 112,00 em dinheiro. Indagado sobre os fatos, Igor respondeu aos militares que havia feito contato com o "Neguinho" no túnel e que ganharia R\$ 100,00 para transportar a droga até a rua Roraima, no Parque Anchieta - local conhecido como ponto de venda de drogas, vulgarmente denominado 'Rocinha' - confissão ratificada ao ser interrogado na Delegacia.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Auto de exibição e apreensão (fls. 10/11). Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12/13). Certidão de distribuição criminal (fls. 35/36). Folha de Antecedentes (fls. 37/40). Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 51/54). Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (fls. 106/108). Defesa Preliminar (fls. 85/87). Recebimento da denúncia (fls. 109/110). Termo de audiência com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu (fls. 128/130). Alegações Finais, na forma de memoriais, do Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 124/127). Alegações Finais, na forma de memoriais, da Defesa, pugnando pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 130/132).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao réu.

Ab initio, passo ao julgamento da presente demanda, na medida em que o MM. Juiz que encerrou a instrução se encontra em gozo de férias. Afirmo que não há que se falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ainda que o referido princípio tenha sido adotado no Processo Penal a partir da edição da Lei nº 11.719/2008, na redação do art. 399, § 2º, do CPP ("O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença"), no presente caso, todo o corpo probatório está presente nos autos, inclusive a inquirição da vítima e interrogatório do réu.

Outrossim, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que: HABEAS CORPUS preventivo com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de nulidade de sentença condenatória por entender haver violação ao princípio da identidade física do juiz. Alegação de que o juiz que presidiu a instrução encontrava-se no gozo de férias no momento de prolação da sentença. Sem razão. Ausência de provas nesse sentido. Sentença assinada pelo próprio juiz que conduziu a instrução, gozando de presunção de veracidade. Ainda que se encontrasse no gozo de férias, nada impediria que fosse prolatada por juiz substituto. Princípio da identidade física do juiz não deve ser entendido de maneira absoluta, devendo ser mitigado em prol do princípio da celeridade processual. No mais, a via eleita mostra-se inadequada, porquanto exige conjunto probatório que extrapola os estreitos limites do writ. Questão que deve ser debatida em sede de apelação. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus 2196451-71.2017.8.26.0000; Relator(a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (grifo nosso).

Ademais, entende a doutrina mais recente, ao comentar sobre a revogação, pelo novo Código de Processo Civil, das exceções que serviam de base para afastamento da vinculação na esfera processual penal:

"A despeito de o art. 132 do CPC estar na iminência de ser revogado pelo novo CPC, que não contempla o princípio da identidade física do juiz, é evidente que, em qualquer ressalva outrora listada pelo referido dispositivo, cessa a competência do magistrado instrutor para o julgamento do feito. (...) Por consequência, sob pena de se admitir que um princípio com status de lei ordinária - identidade física do juiz (CPP, art. 399, §2º) -, possa se sobrepor a um princípio com envergadura constitucional - juiz natural (CF, art. 5º, incisos XXXVII e LIII) -, não se pode

admitir que um juiz que deixou de ter competência para o julgamento do processo em virtude de afastamento legal, logo, incompetente, seja compelido a julgar o feito pelo simples fato de ter presidido a instrução probatória." (BRASILEIRO, Renato. Código de Processo Penal Comentado, 1ª Ed., p. 1102). Portanto, considerando que tal princípio não deve obstar a atividade jurisdicional, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

O policial militar Mateus narrou que estavam em patrulhamento pela área central da cidade quando avistaram o réu Igor que ao visualizar a viatura mexeu na cintura. Pensaram que Igor estava armado e o abordaram. Fizeram a revista pessoal e encontraram com Igor uma bolsa preta com drogas e dinheiro (112 reais). Dentro da bolsa tinha 74 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, um tijolinho de maconha e 22 buchas de maconha. O réu confessou que estava transportando a droga.

O policial militar André narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu Igor mexendo em algo em sua cintura. Pensaram que Igor estaria armado e realizaram a abordagem. Com Igor encontraram uma bolsa preta com drogas (74 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, meio tijolo de maconha e 22 buchas de maconha) e 112 reais em dinheiro. Igor alegou que estava transportando a droga.

Interrogado, o réu Igor narrou que estava passando por dificuldades na época dos fatos. Estava com o aluguel atrasado quando recebeu uma proposta de 100 reais para levar a droga de um bairro para outro. Aceitou a proposta, mas foi abordado pela polícia. Disse que não estava transportando o tijolo de maconha e este foi "plantado" pelo policial.

Passo à análise do crime imputado ao réu.

A materialidade consubstancia-se no Auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12/13) e no Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (fls. 106/108).

A autoria ficou comprovada mediante a prova oral produzida em juízo, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão do réu, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu confessou em parte o delito. Asseverou que, apesar de não ser traficante, naquele dia recebeu uma proposta para entregar drogas na favela do aeroporto, e receberia R\$ 100,00 pelo transporte. Contudo, afirmou que apenas trazia consigo cocaína e "crack", e a maconha teria sido plantada pelos policiais.

Data venia, a versão em parte exculpatória do réu não convence e ficou isolada quando contrastada com o acervo probatório.

Os policiais militares foram uníssomos em dizer que estavam em patrulhamento pela área central da cidade quando avistaram o réu Igor que ao visualizar a viatura mexeu na cintura. Pensaram que Igor estava armado e o abordaram. Fizeram a revista pessoal e encontraram com Igor uma bolsa preta com drogas e dinheiro (112 reais). Dentro da bolsa tinha 74 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, um tijolinho de maconha e 22 buchas de maconha. O réu confessou que estava transportando a droga. Corroborando as palavras dos policiais, o auto de exibição e apreensão de folhas 10/11 descreveu os seguintes entorpecentes apreendidos: 74 porções de cocaína (75g), 140 pedras de 'crack' (40g), 01 tablete de 'maconha' (235g) e 22 porções de 'maconha' (29g).

Impende ressaltar, a inexistência de qualquer óbice em relação ao depoimento prestado por policiais, uma vez que a eles inexiste qualquer impedimento para testemunhar, sendo certo que seus depoimentos são merecedores de crédito como os de qualquer outra testemunha, bem como sujeitos a penalidades se falseado a verdade, que, todavia, não ocorre no presente feito. Nesse diapasão, farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por esses agentes, como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.

Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

Também não há comprovação nos autos de que os policiais teriam imputado falsamente a posse da maconha ao réu.

Desse modo, pelo cenário observado, notadamente pelo réu no momento da abordagem policial estar portando uma bolsa com drogas fracionadas e embaladas prontas para a mercancia, quais sejam, 74 porções de cocaína (75g), 140 pedras de 'crack' (40g), 01 tablete de 'maconha' (235g) e 22 porções de 'maconha' (29g), e pelo fato do réu ter confessado que ganharia R\$ 100,00 para transportar a droga, é certo que elas se destinavam à traficância, restando o ato do réu enquadrado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, pois trazia consigo e transportava drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar com o objetivo de traficá-las.

A combativa Defesa requereu o reconhecimento a aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade, ante a prática delitiva visando auferir dinheiro para alimentar a filha e pagar o aluguel.

O estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Para o reconhecimento do estado de necessidade é necessária a presença de requisitos legais, conforme leciona CÉZAR ROBERTO BITENCOURT:

A configuração do estado de necessidade exige, no Direito brasileiro, a presença simultânea dos seguintes requisitos: existência de perigo atual e inevitável; não provocação voluntária do perigo; inevitabilidade do perigo por outro meio; inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado; direito próprio ou alheio; elemento subjetivo: finalidade de salvar o bem do perigo; ausência do dever legal de enfrentar o perigo. (in Tratado de direito penal: parte geral. Volume 1 - 8ª edição - São Paulo: Saraiva, 2003, p. 259)

Analisando o arcabouço probatório, não há sequer indícios capazes de sustentar a existência do perigo atual, consubstanciada na condição de miserabilidade vivenciada pelo réu.

A Defesa se descuidou de apresentar elementos aptos a sustentar a alegação defensiva, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

Além disso, a inevitabilidade do perigo por outro meio não se encontra preenchida, pois conforme ressalta BITENCOURT, "havendo outra possibilidade razoável de afastar o perigo, essa excludente não se justifica (...). Deve-se buscar a realização do comportamento menos lesivo, desde que suficiente para o mesmo fim" (op cit. p. 262).

Isso porque há a alternativa do desenvolvimento de atividade remunerada lícita, certamente menos lesiva, frente à situação de desemprego, ainda que no mercado informal.

Destarte, aceitar a prática de ilícitos, notadamente o tráfico de drogas, como forma de sustento da família fere de morte princípios basilares do próprio direito, de modo que se poderia cogitar na situação limítrofe de afastamento total das normas jurídicas, indispensáveis à vida em sociedade, para se garantir a sobrevivência de poucos.

De mais a mais, muitos brasileiros, apesar das dificuldades financeiras, não optam pela criminalidade, demonstrando que não é exigível o sacrifício de bens jurídicos tutelados pela norma penal em casos tais.

Demais disso, não se sabe se o contexto de dificuldade financeira não foi provocado voluntariamente pelo réu, o que igualmente afastaria a causa justificante.

Portanto, inadmissível a tese de estado de necessidade ao caso concreto.

Portanto, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de justiça.

Formada a culpa, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não verifico a presença de elementos capazes de alterar a pena, assim, fixo-a no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na segunda fase verifico a reincidência do réu por ter condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 0002495-85.2010.8.26.0642), conforme certidão de distribuição criminal de fls. 35/36. Presente, ainda, a circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que utilizada para a formação do convencimento deste juízo. Consoante entendimento do Colendo STJ, ambas podem ser compensadas, de modo que fica inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena. O réu não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Isso porque, o réu é reincidente, não se enquadrando nos requisitos do referido dispositivo legal. Por isso, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixadas no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico de cocaína e crack, diante de tantas mazelas que sabidamente estas drogas provocam. Verifico também ausentes os requisitos viabilizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no art. 44 do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada (mais de 04 anos) e pela reincidência do réu em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu IGOR DA SILVA BARROS no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixadas no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que permanecem presentes os fundamentos constantes da r. decisão que a decretou. Acrescente-se àqueles argumentos a gravidade concreta da ação praticada, expostas linhas acima, mais precisamente na motivação da escolha do regime inicial fechado para o crime de tráfico de drogas.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento do réu, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, oficiando-se.

Encaminhe-se a bolsa apreendida para destruição.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido com o réu em favor da União revertido ao Funad, nos termos do artigo 63 da lei 11.343/2006.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Custas ex legis, observada a gratuidade de justiça concedida.

Expeça-se a certidão de honorários para o Defensor nomeado.

Arquivem-se os autos oportunamente.

Publique-se e intime-se.

Ubatuba, 17 de janeiro de 2022.

MARGEM DIREITA